

0000659-94.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3218/2021 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVALDO SANTANA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Genivaldo Santana Junior, devidamente qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000659-94.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000659-94.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3218/2021 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVALDO SANTANA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Genivaldo Santana Junior, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está

sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2021, por volta de 14h50min, na Rua São Carlos, altura do nº 26, Jd. dos Reis, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo e guardava, para fins de venda, as seguintes drogas: a) 88 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 144g de massa bruta; b) 39 "pedras" de crack, pesando, aproximadamente, 36g de massa bruta c) 26 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 15g de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo definitivo a ser juntado, além da quantia de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em notas trocadas.

Laudo de exame pericial prévio de constatação da droga às fls. 15/17.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 26 e 81/82.

A denúncia foi recebida à fl. 72, em 05 de novembro de 2021.

Regularmente citado e notificado (fl. 87), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 98/100.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 58/60.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Rogério Leão do Amaral e Walter Simão da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa, gravadas em sistema audiovisual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

Destaco que a alegação de nulidade probatória suscitada pela Defesa se confunde com o mérito, e, portanto, com este será analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 07/08, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 15/17 e fls. 98/100, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Rogerio Leão do Amaral, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistou o Réu, que se evadiu, desfazendo-se de uma sacola. Ato contínuo, os policiais apreenderam a sacola dispensada e detiveram o acusado. No interior do referido objeto, havia drogas diversas e quantidade de dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha Walter Simão da Silva, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava na viatura, em patrulhamento pelo Jardim dos Reis, quando avistaram o Réu, que tentou empreender fuga. Encontraram sacola preta na posse do acusado, com drogas em seu interior. A referida sacola foi apreendida na posse direta do Réu. Já havia realizado abordagem do acusado em ocasião anterior, em circunstância de tráfico também. O fato anterior ocorreu cerca de uma semana antes, mas ele acabou sendo solto na audiência de custódia.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

"Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o

que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos guardas municipais só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista esse se encontrava em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e, ao avistar os agentes públicos, tentou imediatamente empreender fuga -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que veio do Piauí para trabalhar em São Paulo, mas acabou ficando desempregado. Por conta disso, aceitou a função de olheiro na biqueira. No dia dos fatos, avisou aos "meninos" a presença dos guardas municipais e eles saíram correndo. As drogas foram dispensadas por aqueles, não se encontrando na posse do declarante. Informou que recebia cerca de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro ou marmitta.

Em que pese a versão exculpatória apresentada pelo Réu, essa se encontra dissociada do restante do conjunto probatório e da realidade fática, não sendo crível que guardas municipais tivessem tentado lhe atribuir a posse de drogas à revelia da lei, sem motivo concreto para tanto e, ainda, colocar em sua posse a quantia de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), conforme auto de exibição/apreensão de fls. 07/08. No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 07/08, em mais de cento e cinquenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros. Conquanto tenha havido contradição entre os agentes públicos acerca da localização da sacola com entorpecentes (se nas mãos do acusado ou em local por esse dispensado), ambos os guardas municipais foram uníssonos em apontar que os entorpecentes estavam na posse do Réu – seja essa direta ou indireta –, não havendo, in casu, contradições sobre os pontos principais de sua narrativa fática, necessários à caracterização do tráfico.

Com efeito, ambos os guardas municipais relataram que, tão logo avistou a viatura, o acusado empreendeu fuga, estando os entorpecentes e o dinheiro apreendidos na sacola em que o Réu portava quando avistado.

No mais, consoante se depreende da certidão de antecedentes criminais do acusado (fls. 81/82), esse foi preso tanto no dia 08/10/2021 quanto no dia 14/10/2021 por crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo razoável conceber que os guardas municipais ouvidos em juízo tenham se confundido sobre pontos secundários da abordagem, ante a similaridade de suas circunstâncias e proximidade de datas. Deste modo, inviável a desclassificação para os crimes de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06) ou colaboração com o tráfico (art. 37, Lei nº 11.343/06), ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como os relatos dos guardas municipais vinculando as drogas apreendidas à conduta do acusado.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Destaco que a quantidade da droga (209,4g brutos – fls. 16/17) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes. Deixo de aplicar o disposto no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, em razão de o delito não guardar relação com a situação de calamidade pública – essa não facilitou, influenciou nem foi causa para a prática do delito.

Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes (certidão de fls. 26 e 81/82), bem como a

ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Apesar de o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispor que a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena – sendo possível a compreensão de que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos –, entendendo ser necessário que haja, ao menos, sentença condenatória proferida em outro processo ou a verificação de situações evidentes, tais quais prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo, de modo a impedir a incidência da minorante em questão. Como nos autos do processo nº 1502478-89.2021.8.26.0544 não houve condenação do Réu nem em primeira instância e não há provas nos autos que comprovem prisões reiteradas anteriormente aos fatos em questão, não é possível aferir, com algum grau de certeza, que este, de fato, se dedica à prática de atividades ilícitas. Em outras palavras, inexistindo sequer condenação em primeiro grau de jurisdição, a presunção de não culpabilidade do acusado permanece hígida, não sendo mitigada pela simples existência de inquérito ou processo judicial em curso. Ademais, caso seja afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 em razão da existência de ação penal em curso e o Réu venha a ser nessa inocentado ulteriormente, a fundamentação desta sentença terá se baseado em fato não reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, o que importaria em contradição na prestação jurisdicional.

Logo, ante a ausência de ao menos sentença condenatória em tal processo – com vistas a mitigar a presunção de inocência do Réu quanto ao envolvimento em associação criminosa –, inviável acolher o pedido de afastamento de causa minorante da pena nesta decisão, com base na existência de apenas uma ação penal em curso, cuja instrução sequer se encontra finalizada.

Ademais, o fato investigado nos autos do processo nº 1502478-89.2021.8.26.0544 ocorreu em data posterior ao apurado nos presentes autos, o que inviabiliza a sua consideração para verificar maus antecedentes e/ou personalidade do Réu ao tempo do crime sob exame, não podendo ser utilizado, igualmente, para concluir se o acusado já se encontrava praticando, em 08 de outubro de 2021, tráfico de forma reiterada. Sendo assim, reduzo a pena em 1/3, diante da quantidade da droga e das circunstâncias da prisão do agente. Deixo de efetuar a redução em seu máximo em razão da natureza variada dos entorpecentes apreendidos e excessiva pulverização (em mais de cento e cinquenta invólucros).

Fixo, portanto, a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Genivaldo Santana Junior como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333

(trezentos e trinta e três) dias-multa, estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a prática delitiva, mediante a substituição por restritivas de direito, nos moldes acima fixados.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), praticando o delito de tráfico, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06, porquanto inexistentes nos autos provas que permitam inferir que tal quantia não se originou das vendas realizadas no âmbito do crime em questão.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto, e a substituição por restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura clausulado (anoto que o acusado se encontra respondendo concomitantemente ao processo de nº 1502478-89.2021.8.26.0544).

Expeça-se guia de execução provisória, se o caso.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA